

实践中，刑民交叉型诈骗犯罪主要包括三种手段：一是“请托型”，通过承揽某项事务的方式从被害人处骗取财物。二是“交易型”，通过商品购销的方式从被害人处骗取财物。三是“借贷型”，通过借款的方式从被害人处骗取财物。本案就属于典型的“请托型”诈骗犯罪。被告人张某虚构能够帮助被害人赵某母亲脱罪的事实，使得赵某形成相信张某真的能够帮助自己的认识错误，并基于此认识错误交付给张某人民币300万元，张某的行为足以说明其欺骗程度已经远远超出民事欺诈范畴，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

（二）非法占有目的方面

在某些情况下，民事欺诈和刑事诈骗在行为方式上是完全相同的，因此不能简单从行为方式上进行区分，而是要从行为人的主观是否具有非法占有目的上予以区分。只有诈骗罪才具有非法占有目的，而民事纠纷中的欺诈行为则没有非法占有目的。对请托型诈骗，非法占有目的应结合行为人是否具有履约能力、是否实施履约行为、对取得财物的处置措施等情况综合考量。按照从客观到主观的原则，诈骗罪在客观上表现为一个特定的发展过程：行为人实施欺骗行为—对方陷入认识错误—对方基于认识错误处分财产—行为人取得或者使第三者取得财产—被害人遭受财产损失。认定行为人构成诈骗，上述过程缺一不可，一旦某个环节出现缺失或者加入介入因素，就极易构成诈骗罪认定的阻断。

本案中，张某否认收取被害人两笔钱款。法院在根据证据对张某收取钱款行为进行确认后，对张某行为的定性，重点从被害人错误认识是否产生角度进行论证，从而得出被害人系基于认识错误处分的财产之结论。

被告人张某虚构自己具有办理请托事项的能力，使被害人赵某陷入错误认识，被害人赵某基于错误认识先向被告人张某交付了300万元。被害人赵某虽然前后陈述存在部分变化，但其就给张某钱款的缘由系为了帮自己母亲脱罪的陈述基本一致，现有证据能够证明张某在赵某给其钱款的前后，有给赵某介绍律师、陪同赵某前往河南探视赵某之母等积极参与的行为，上述行为与赵某所述之给钱缘由能够呼应，且上述300万元均系来自赵某本人。结合生活常识来看，300万元并不是小数目，被害人不可能无缘无故给被告人300万元，被告

人实施一系列积极行为背后有金钱利益驱动。被告人张某对于300万元有明显的非法占有目的，与后续被害人交由其保管260万元的性质完全不同，无法将剩下的260万元也认定为被告人的诈骗金额。

二、被害人参与程度较高可能构成诈骗罪认定的阻断

请托型诈骗中，被害人与行为人之间通常会有较为频繁的“互动沟通”，在请托事项无须行为人具有特定能力或资格，而仅系帮忙型请托时，行为人如按照与被害人所沟通内容对被害人钱物作出一定处分，在钱物不能按照约定返还时，不宜直接从外观来判定行为人在行为之时是否具有非法占有目的，而应重点审查被害人在整个事件中的参与程度，在依据证据判定被害人对行为人的行为参与度超出普通认知的“沟通”时，就不存在被害人基于认识错误处分财产的情形，从而构成认定行为人行为构成诈骗罪的阻断。

本案中，针对被害人赵某给张某的260万元，从二人的沟通情况来看，对被告人张某所存钱款，张某让渡了部分决定权，被告人赵某享有一定程度的支配权。从张某存款时赵某的参与度来看，赵某对办卡存钱有支配权。赵某在其母亲被判刑后有转移其母亲名下财产的主观意图，其除了将其母亲的260万元给张某保管，赵某亦有在之后继续从其母亲账户转入自己账户数笔钱款的行为。故，在被害人赵某参与了张某的存款过程且享有一定支配权的情况下，不存在赵某系基于认识错误处分财产的情形，从而构成认定张某对260万元构成诈骗罪的阻断。

三、不能依据行为人在基于被害人授权处分被害人钱物后产生占有钱物的事后故意，认定行为人构成诈骗罪

在被害人参与程度较高从而阻断诈骗罪的认定后，双方的行为即为典型的民事行为，如果行为人在事后产生占有被害人钱物的故意，不能据此反向认定行为人构成诈骗罪。

本案中，对260万元应当如何定性？即行为人占有对方当事人委托其保管的财物后，临时产生非法占有目的，拒不退还或擅自处分，究竟是成立诈骗罪还是侵占罪。一种观点认为，构成侵占罪，因为财物系行为人合法保管，欺骗

的因素只是为了掩盖其非法占有的事实。另一种观点认为，构成诈骗罪，因为行为人以虚构事实的方法非法占有财物。侵占罪属于“非转移占有型”犯罪，客观表现为被害人基于委托、信任等原因自愿地将财物交给行为人，行为人占有他人财物与欺诈行为没有因果关系，而是另起犯意将合法控制之下的财物非法占有，且拒不退还。诈骗犯罪属于“转移占有型”犯罪，行为人自始不具备归还意思，并采取虚构事实、隐瞒真相等方法，使得被害人基于错误认识将财物交给其占有。如果行为人在财物转移占有之前没有非法占有目的，即使事后采取了一定的欺诈手段，如谎称财物被盗、丢失、损毁等而拒不归还，对方当事人并未丧失追索权的，不应按照诈骗罪处理。但是，如果行为人在财物转移占有之后，通过欺诈手段使对方当事人免除返还义务或丧失追索权的，同样属于财物处分行为，应按照诈骗罪处理。本案中，张某在赵某转移给自己占有260万元之前，对这笔钱并没有非法占有目的（只是帮助理财），张某后来拒绝返还这笔钱，但不存在以欺诈手段拒不归还的行为，赵某也未对这笔钱丧失追索权，张某对这260万元不成立诈骗罪，260万元不应纳入诈骗金额之中。

编写人：北京市第三中级人民法院 魏颖 申倩

控制交易型类金融交易平台犯罪行为构成诈骗罪

—— 杨某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第二中级人民法院（2022）沪02刑终510号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

杨某为某公司股东，2016年至2017年4月，某公司申请成为某1公司下属会员单位，并托管三组邮票。其间，被告人杨某伙同他人以电话、网络销售的方式吸引客户至公司直播平台听课，配合业务员以邮币卡的涨势诱骗客户开户入金，操盘手利用邮票数量、手续费等优势操作邮票的上涨和下跌，并通过业务员喊单的方式不断诱骗客户入金上述三组邮票，操盘手反向高抛低买，以此赚取客户亏损。经审计，至案发，仁某某、钟某某等27名被害人入金共计2592万余元，出金共计2392万余元，差额188万余元(除去案发前仁某某获赔金额)。

【案件焦点】

1. 被告人杨某的行为如何定性；
2. 杨某的犯罪金额如何认定。

【法院裁判要旨】

上海市宝山区人民法院经审理认为：被告人杨某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人杨某的供述和同案关系人李某、王某等人的供述相互印证，证实某公司在涉案邮币卡交易过程中，隐瞒公司控盘交易的事实，以高额投资回报引诱被害人投资，继而收割被害人财产，其行为实质上是以暗中操纵邮票涨跌价格为手段，以赚取被害人损失为目的所实施的诈骗犯罪活动。上述犯罪活动与合法市场上的非法经营、操作证券市场等行为有着显著区别。在共同犯罪中，被告人杨某负责操盘交易，作用重要，不宜认定为从犯。证人孙某的证言与公安机关出具的《工作情况》相互印证，证实被告人杨某没有主动投案的行为，故不符合自首的认定条件。被告人杨某到案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨某主动退缴所涉违法所得，并取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，综合被告人杨某的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，判决如下：

- 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。

二、在案赃款发还相关被害人；不足部分，责令继续退赔。

一审宣判后，杨某提出上诉。

上海市第二中级人民法院经审理认为：原审法院根据上诉人杨某的犯罪事实、性质、情节及退赔等情况所作判决并无不当，且审判程序合法。上诉人杨某的上诉理由不成立。上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，作出如下裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于杨某以暗中操纵价格涨跌为手段，以赚取被害人损失为目的所实施的诈骗犯罪活动如何定性及杨某的犯罪金额如何认定。

一、杨某的行为构成诈骗罪

控制交易型类金融交易平台犯罪案件即行为人自建平台或成为平台会员单位，前期诱导客户入金交易后，通过操控平台交易系统控制价量，利用反向行情指导收割投资人资金。此类案件多以小众投资标的为噱头，如文化艺术品、邮币卡、虚拟货币等。控制交易型是典型的利用非法平台实施诈骗犯罪案件，对行为人以诈骗罪论处当无疑义，关键在于控制交易的认定。随着犯罪分子反侦查意识的增强，相关交易平台多设置在境外，直接查获交易平台的情形较为少见。实践中需要梳理分析全案证据，通观一个投资周期事前、事中、事后不同阶段的行为表现，进行综合判断。在案证据证实，行为人事前明知以客损为利，事中提供反向操作指导，事后又毁证逃匿的，即足以认定所涉平台是控制交易型平台。

本案中，杨某作为某公司的股东，某公司申请为某1公司下属会员单位，前期通过电话、网络销售的方式，以邮币卡为噱头，诱导客户入金交易，在涉案邮币卡交易过程中，隐瞒公司控盘交易的事实，通过操控平台交易系统控制价量，利用反向行情指导收割投资人资金，其行为实质上是以暗中操纵邮票涨跌价格为手段，杨某等人的行为属于典型的利用非法平台实施诈骗犯罪案件，即属于控制交易型类金融交易平台犯罪。杨某等人的犯罪行为与市场上的非法

经营、操作证券市场等行为有着显著区别，故应当以诈骗罪追究杨某刑事责任。

二、杨某的犯罪数额认定

资金流向查证属实，犯罪数额的计算才有据可依。类金融交易平台犯罪案件中，计算犯罪数额时主要涉及3个数字，即入金金额、出金金额、冻结金额。以不同罪名认定犯罪行为，所涉犯罪数额的计算方法也不相同。对于非法经营罪而言，将入金金额认定为犯罪金额具有合理性；对于诈骗罪而言，入金金额减去出金金额（净入金金额，又称客损）是常规计算方式，投资标的为邮币卡、文玩份额等真实存在且有一定价值的物品时，犯罪金额以净入金金额再扣减冻结金额计算，更为合理。

本案中，杨某伙同他人以电话、网络销售的方式吸引客户至公司直播平台听课，配合业务员以邮币卡的涨势诱骗客户开户入金，操盘手利用邮票数量、手续费等优势操作邮票的上涨和下跌，并通过业务员喊单的方式不断诱骗客户入金，操盘手反向高抛低买。其中，诱骗客户开户入金25927324.60元，出金23923917.90元，根据诈骗罪计算方法，本案的犯罪金额为入金金额减去出金金额以及案发前被告人杨某退还被害人的金额120000元，即本案犯罪金额为1883406.7元。

三、遵循从客观到主观的主客观相统一的基本路径区分个体共犯责任

本案中，杨某的辩护人提出杨某的行为较其他同案犯的行为作用小，在共同犯罪中，应认定为从犯。对于类金融交易平台犯罪案中共谋诈骗手法、知晓平台性质、清楚资金流向的行为人，以诈骗罪定罪自无疑义，但对仅招揽意向投资人、不明知核心业务模式的低阶层业务员，以诈骗罪论处有悖于主客观相统一的犯罪认定原则。因此，实践中应注意区分行为人由于层级、职责分工、获取利益方式、对全部犯罪事实知情程度等的不同，以此认定行为人是否具有非法占有他人财物的目的，予以分别认定为诈骗罪和非法经营罪。

遵循从客观到主观的主客观相统一是我国刑事司法实践认定犯罪构成的基本路径。对于类金融交易平台犯罪案件而言，所谓损失究系为行为人骗取还是正常市场波动所致，决定了两罪之争的主要方向，在此也涉及主客观两个方面

的内容。其中，客观方面主要是指资金流向的查证，重点解决案件整体定性；主观方面主要是指非法占有目的的认定，主要用于区别共犯人责任。两个方面相辅相成，并在一些情形下互相支撑印证。

本案中，客观方面河北滨某大宗邮币卡平台下其他会员公司，发展各地交易商和经纪商会员、客户，通过操盘方式诈骗客户的钱财；主观方面杨某作为某公司股东，对于平台性质系明知，其负责操盘交易对于资金的流向亦是明知，故本案中，杨某在共同犯罪中的作用重要，不宜认定为从犯。

编写人：上海市宝山区人民法院 张国滨 牛玲玲

利用手机软件针对特定人实施诈骗的 不宜认定为电信网络诈骗

—— 卓某某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

安徽省淮南市中级人民法院(2023)皖04刑终185号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2021年7月17日22时许，被害人程某某在家中玩手机时，被告人卓某某通过某二手交易平台联系程某某，欲购买被害人“和平精英”的游戏账号，双方约定游戏账号交易价格为37000元。卓某某提前付款给“闲鱼”第三方平台后，便向被害人索要游戏账号相关信息。程某某通过微信将自己登录“和平精英”网游的微信号、微信密码、微信支付密码和“和平精英”二级密码(用于

转赠装备)发给卓某某。卓某某获取相应信息后，便解除账号与被害人程某某的绑定关系，并向“闲鱼平台”申请退款。

2021年11月，被害人张某某以23000元的价格从他人处购买“和平精英”游戏账号，后通过某二手交易平台将该账号出售。被告人卓某某使用昵称为“K××”的微信账号与被害人张某某联系，谎称自己为女性，并使用蔡某某身份信息与被害人张某某聊天。被害人将游戏账号、密码告诉卓某某后，卓某某便修改游戏账号和密码并将游戏账号绑定自己的身份证，导致被害人张某某无法登录。为防止被害人张某某联系，卓某某又拉黑对方。2021年12月6日，卓某某以陈某某名义以14000元价格将该游戏账号转卖给李某某。2021年12月8日，在扣除平台手续费后，陈某某按照卓某某要求将13000元转给卓某某。案发后，被告人卓某某退赔李某某7000元，退还程某某37000元，退还张某某23000元，并取得二被害人谅解，签署认罪认罚具结书，退缴违法所得6000元。

【案件焦点】

利用手机APP软件对特定人实施诈骗的能否认定为电信网络诈骗。

【法院裁判要旨】

安徽省淮南市田家庵区人民法院经审理认为：被告人卓某某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，价值60000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚和从宽处罚；案发后赔偿被害人全部经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚和从宽处罚。卓某某在案发时虽是在校学生，却沉迷于网络游戏，并由此谋取生财之道，冒用他人身份、隐瞒性别和个人信息在网络上实施诈骗，其诈骗手段具有更大的危害性和欺骗性，为严惩电信网络诈骗犯罪活动，保护公民的合法权益，法律也规定要求对此类实施诈骗的被告人裁量刑罚时应就高选择，并应严格控制适用缓刑的范围。对实施诈骗犯罪的被告人而言，其退赃退赔是

刑法规定被告人必须予以追缴和退赔的，而不应成为对其适用缓刑的条件，公诉机关提出的起点刑有期徒刑三年的量刑意见已充分考虑到被告人卓某某的从

轻、从宽处罚的量刑情节，对公诉机关和辩护人提出要求适用缓刑的意见不予支持。据此，以诈骗罪判处被告人卓某某有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。

一审宣判后，卓某某提出上诉。

安徽省淮南市中级人民法院经审理认为：上诉人卓某某以非法占有为目的，利用互联网平台骗取他人财物，价值60000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。但其采取利用网络平台漏洞或者向被害人谎称女性身份的方式，骗取了本案两名被害人网上游戏账号，造成被害人经济损失，行为不符合电信网络诈骗犯罪规定的利用电信网络技术手段，针对不特定群体侵害的特征。同时，鉴于卓某某到案后如实供述，认罪认罚，积极退赃退赔，并取得被害人的谅解，且对其所居住社区没有重大不良影响，综合考虑卓某某的犯罪事实及归案后的认罪态度、悔罪表现等情节，可对其适用缓刑。据此判决：

上诉人卓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。

【法官后语】

一、关于电信网络诈骗犯罪的特征

电信网络诈骗犯罪除符合传统诈骗罪的构成要件外，还具有技术性、非接触性、远程性以及针对人群的不特定性等特征。一般可以概括为，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，针对不特定多数人所实施的远程式、非接触式诈骗犯罪。

二、本案是否属于电信网络诈骗犯罪

（一）电信网络诈骗所针对人群的具有不特定性

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项规定，通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，可以酌情从严惩处。从法律规定的犯罪手段可以看出，电信网络诈骗具有以点带面、一对多的犯罪特点，而非针对特定人实施诈骗行为，普通的诈骗犯罪在

着手实施犯罪行为时就已明确作案目标。本案中，被告人通过手机APP 交易平台软件看到被害人出售游戏账号的信息，然后虚构自己要购买的事实，隐瞒欲通过平台漏洞非法占有对方财物的目的，在骗取被害人的账号、密码后，将对方账户拉黑并通过申请退款的方式非法占有对方财物。此时，行为人与特定人之间系点对点、一对一的联系，仍限于特定的空间范畴，具有一定的私密性，没有对其他不特定人产生影响，与电信网络诈骗针对不特定人群的方式有明显不同。因此，本案中被告人针对特定人实施的诈骗犯罪，即使利用了手机APP、网络工具，从诈骗对象不特定多数性的角度也不宜认定为电信网络诈骗犯罪。

（二）电信网络诈骗具有全链条、分工合作的特点

电信网络诈骗产业分工日益完善，上下游及诈骗实行行为独立化、专业化、多层级分工协作，上中下游犯罪全覆盖，形成了包括贩卖公民个人信息，倒买倒卖银行卡、电话卡，为犯罪提供技术支持，洗钱等组织分工严密的黑灰色产业链条。本案中，仅被告人个人单独实施两起诈骗犯罪，不属于犯罪链条上的任何一个环节，与立法严惩电信网络诈骗犯罪的宗旨相去甚远。

（三）准确认定电信网络诈骗性质是公正判决的基础

本案的争议焦点是被告人实施的行为能否认定为电信网络诈骗，认定与否将直接影响对被告人的量刑。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分“依法严惩电信网络诈骗犯罪”第七条的规定，对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。本案二审之所以改判适用缓刑，是基于否定被告人实施的行为属于电信网络诈骗犯罪，而是普通的诈骗犯罪，为适用缓刑排除了适用法律的障碍。

编写人：安徽省淮南市中级人民法院 王毅全

(四)职务侵占罪

65

法定节假日公司值班人员“监守自盗”可认定为职务侵占罪

——谭某某职务侵占、盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02刑终276号刑事裁定书

2. 案由：职务侵占罪、盗窃罪

【基本案情】

1. 盗窃罪部分(略)。

2. 职务侵占罪。2023年1月，谭某某利用其系被害单位主管，负责值班巡查库房之机，多次盗走上述基地内的充电枪共计412根。后销赃给他人，得款已挥霍。经价格认证中心认定，被盗充电枪价格为205元/根。综上，谭某某盗窃数额共计35670元，职务侵占数额共计84460元。2023年2月20日，谭某某主动到公安机关投案，并如实供述上述事实。案发后，公安机关已追回被盗充电枪433根，并返还被害单位。谭某某的家属已代为退出违法所得8000元，代为退赔充电枪53根给被害单位，并获得被害单位的谅解。综上，谭某某共窃取、侵占公司充电枪586根。

【案件焦点】

法定节假日期间，公司值班工作人员实施窃取公司财物的行为是否应该认定为职务侵占罪。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：谭某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为构成盗窃罪。谭某某利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。谭某某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。谭某某具有自首、认罪认罚、赔偿被害单位部分经济损失并取得谅解、退赃情节，依法可以从轻或者减轻处罚。谭某某具有多次盗窃、职务侵占行为，对其量刑时予以从重考虑。关于辩护人辩称谭某某的行为属于构成想象竞合犯，应以职务侵占罪定罪的辩护意见，法院认为，谭某某的职责主要是负责公司新能源车的装卸作业和现场管理，负责对接火车站货运中心等工作，其只有在2023年1月，因为接受单位安排值班，对新能源汽车财物安全进行夜间巡视，具有安保职责，平素公司有专门的安保人员对车辆进行看守，故只有在其值班期间实施的行为才属于利用职务便利，其他时候实施的盗窃行为跟职务无关，故依法应该实行数罪并罚。另外，根据想象竞合犯的理念，一个行为触犯两个罪名时，应该从一重罪进行处罚，在本案中即应该按照盗窃罪进行处罚，并非辩护人辩称的以职务侵占罪进行处罚，故对辩护人该辩护意见，不予采纳。关于辩护人辩称谭某某具有自首、坦白等其他从轻或者减轻情节，与事实相符，予以采纳。综上，鱼峰法院决定对谭某某适用从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，作出判决如下：

一、谭某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金3万元；

二、谭某某退缴的违法所得8000元，予以返还被害单位；被暂扣的手机，予以没收上缴国库；

三、责令谭某某继续赔偿被害单位经济损失12500元。

上诉人谭某某对一审判决不服，请求二审查明事实，依法对其判处缓刑。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据我国现行刑法理论，对于监守自盗行为，不应以存在“盗”字一律定义为盗窃罪，而应该根据犯罪构成理念，准确界定罪名，充分达到定罪精准、量刑合理。监守自盗行为由于存在职务看管行为的前提，在具体案例中应具体分析，根据是否利用了其职务便利以及利用的程度，来准确界定是否构成职务侵占罪。本案中，谭某某的行为构成职务侵占罪，可以从以下几个方面分析。

1. 存在对公司财物具有管理职权。基于职务的管理职权而侵吞财物，可以构成职务侵占罪，没有基于职务的管理职权，但是受托管理财产的，可以构成侵占罪，没有管理职权，也没有合法占有财物的其他原因，单纯是利用对环境的熟悉和便利，则可能构成盗窃罪等其他犯罪。本案中，谭某某系被害单位主管，其在国家法定节假日期间被公司安排值班，将单位库房内的充电枪拿走并贩卖，其在法定节假日被公司安排值班，理所当然对公司的财产安危、险情防控等具有必然的管理责任，即对充电枪的保管、存放、遗失等均有直接管理责任。

2. 存在利用职务便利情形。顾名思义，职务侵占，理所当然就是存在利用职务便利的情况，如果仅仅是熟悉环境，而非利用其管理财物的职务便利窃取财物，则可能构成盗窃罪。例如，公司普通生产线员工趁老板下班潜入老板办公室将电脑拿走则构成盗窃罪。本案中，谭某某在非法定节假日期间，利用其对公司内部环境熟悉的优势，偷偷将充电枪拿走贩卖，构成盗窃罪，公诉机关亦进行了指控。但在法定节假日期间，其作为公司值班人员，可以轻松便利地接触到公司所有财物，此时将公司财物拿走可以说是存在利用职务便利的情形。

3. 行为模式一致背景下就低选择入罪罪名能够充分有力地打击犯罪。入罪时举轻以明重，出罪时举重以明轻这是刑法基础理论。虽然《中华人民共和国

刑法》对每个罪名的行为模式、主客观心理状况、所侵犯的对象等方面都有详细的规定，但是司法实践中一个行为完全可以触犯两个不同的法条，也可能存在同样的犯罪构成模式，却存在截然不同的司法裁判结果。前一种情形在法理上可以解决，后一种情形则有时需借助其他证据来佐证判断，在达不到刑事证据充分、排除一切合理怀疑的证明标准的情况下，以最低标准的轻罪认定。合理怀疑不仅涉及行为事实等客观逻辑上，也对作案时的主观动机等思维化内容可以适用。换言之，本案中，谭某某实施的行为很清晰，即将单位的东西拿走贩卖，但其辩称在其值班时属于利用职务便利。由于监守自盗型盗窃并不完全具备隐蔽性和秘密性特征，如果以盗窃论处则无法排除其利用职务便利去接触单位财物进而在职权掩盖下窃取单位财物的合理性，故不宜轻易以盗窃论处。结合二罪入罪标准和谭某某所窃取充电器的价值，以职务侵占罪定罪更加能够实现罪刑法定原则，亦可排除其他主观方面的合理辩解。

编写人：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 谢剑峰

保险代理人作为职务侵占犯罪主体之辨析①

—— 徐某某、朱某某职务侵占、侵犯公民个人信息案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市静安区人民法院(2021)沪0106刑初735号刑事判决书

2. 案由：职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪

①入库案例，参见人民法院案例库2023-05-1-226-003。

【基本案情】

一、职务侵占罪

被告人徐某某、朱某某于2020年4月起组织“保险黑产”犯罪团伙。2020年4月至6月，由徐某某先与被害单位某保险公司上海分公司现代部业务总监 徐某1共谋，由徐某1指使该部门业务主任张某、顾某某等人提供保险业务团队内新人业务员账号；再由徐某某、朱某某从他人处购买保险公司客户投保的交易信息，将信息交由“保险黑产”犯罪团伙成员冒充某保险公司员工与客户取得联系，采用“撬单”或其他方式促成客户在某保险公司购买新的保单。徐某某、朱某某等团伙成员再将上述销售的新保单挂单在张某、顾某某等人提供的新人业务员账号下，以此骗取某保险公司上海分公司对新人业务员提供的新人训练津贴、增员奖等额外奖励共计184.8万余元。赃款由“保险黑产”犯罪团伙成员与某保险公司内部人员进行分赃。

二、侵犯公民个人信息罪

1.被告人徐某某、朱某某于2020年4月至6月，由徐某某提供资金、由朱某某负责联系，通过陈某向黄某以每条80元至130元不等的价格购买包含保单号、投保日期、保险险种、保单金额、客户姓名、身份证号码、家庭住址、电话号码等内容的保险交易信息共计1万余条。经查，用于购买保险交易信息的金额共计154万余元。

2.被告人徐某某于2020年8月，以每条50元的价格向某保险公司上海分公司运营督导部员工肖某购买包含投保日期、保险险种、保单金额、客户姓名、身份证号码、家庭住址、电话号码等内容的保险交易信息数百条，并支付肖某3.95万元。

2020年10月29日，被告人徐某某、朱某某被公安人员抓获。到案后，被告人徐某某拒不供认上述犯罪事实；被告人朱某某对职务侵占一节事实未能如实供述，但主动交代了侵犯公民个人信息一节事实。在审理过程中，被告人徐某某、朱某某均能如实供述全部犯罪事实，且徐某某退出违

276 中国法院2025年度案例·刑事案例三

法所得39万元、朱某某退出违法所得30万元，连同其他同案关系人已退出全部违法所得。

【案件焦点】

1. “保险黑产”团伙中参与犯罪的保险公司内部人员均系与保险公司签订保险代理合同书的保险代理人，保险代理人是否属于保险公司的工作人员；
2. 是否符合职务侵占罪所规定的主体身份及具有职务便利的构成要件。

【法院裁判要旨】

上海市静安区人民法院经审理认为：关于争议焦点。

一、保险代理人可以视为保险公司工作人员

同案关系人徐某1、张某、顾某某等人与某保险公司上海分公司签订保险代理合同书，接受保险公司的培训与管理，对外以保险公司的名义开展保险业务，从形式上看似与保险公司属于委托代理关系。但从实质上看，保险代理人以保险公司名义为公司代办保险业务，保险公司从相关业务中获得保费收入，从中再支付保险代理人佣金；为保证保险代理人的工作质量，保险公司还为保险代理人组织培训，安排监督人员实施严格的管理手段；这均与一般公司工作人员的实质属性相同。两者的区别仅在于赚取收益的形式不同，保险公司签订保险代理合同的根本目的在于保险代理人的用工成本相对较低，不需要为保险代理人支付基本工资及缴纳社保，保险代理人通过实际展业的业务量赚取佣金能够形成激励机制，为保险公司创造收益。因此，仅以支付报酬的方式不同不足以区分保险代理人与保险公司工作人员之间的界限，保险代理人具有职务侵占的主体身份条件。

二、保险代理人具有保险公司工作人员的职务便利

同案关系人徐某1、张某、顾某某等人具有一定上下级的管理关系。某保险公司上海分公司的保险代理人采取多层级的管理模式。一般由资深的保险代理人邀请新人保险代理人加入保险公司，被邀请者的数量达到一定标准后，邀请者则晋升为业务主任，对被邀请者们进行管理并从其中的业务分成，被邀请者也可以继续邀请他人加入，当团队规模到达一定标准后，业务主任也可以晋升为部门业务总监、地区业务总监等，管理方式和业务提成以此类推。同案犯徐某1、张某、顾某某等人虚构新任保险代理人，实际由他人展业，挂单在新

